

1501379-24.2021.8.26.0079

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Comarca: Botucatu

Foro: Foro de Botucatu

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... tese, estariam a configurar os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com causa de aumento de pena.

Primeiramente cabe analisar a matéria arguida em preliminar pela defesa.

Verifico que o pleito de rejeição de plano da denúncia, ao argumento de que não existiu conduta de tráfico por parte do réu é matéria afeta ao mérito da ação, e nele será ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Botucatu

Foro de Botucatu

1ª Vara Criminal

PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501379-24.2021.8.26.0079 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501379-24.2021.8.26.0079

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2157675/2021 - DEL.SEC.BOTUCATU, 18433451 - DEL.SEC.BOTUCATU, 621/21/200 -

DEL.SEC.BOTUCATU, 2157675 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 621/21/200 - DISE-

DEL.SEC.BOTUCATU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO MATHEUS RODRIGUES DA SILVA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Vistos.

JOÃO MATHEUS RODRIGUES DA SILVA qualificado nos autos, foi denunciado e viu-se processado como incurso nos artigos 33, "caput", e 35, "caput", c.c. o artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 29, "caput", e do artigo 69, "caput", ambos do Código Penal, porque no dia 10 de junho de 2021, por volta das 21h00min, na Rua Mirabeau Camargo Pacheco, via pública, altura do nº 597, Conjunto Habitacional L. Roque Ortiz Filho, nesta cidade e comarca de Botucatu/SP, previamente ajustado e com unidade de desígnios, juntamente com o adolescente L. B.T. (fls. 10/11), trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiras

pessoas, 96 porções de cocaína, individualmente embaladas e prontas para a venda, com peso líquido de 8,34g, e 66 porções de cocaína na forma de 'crack', também individualmente embaladas e prontas para a venda, com peso líquido de 15,95g, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 25/27), laudo de constatação provisória (fls. 29/37) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 110/112) acostados aos autos.

Consta, ainda, dos mesmos autos de inquérito policial que, em data e local incertos, anteriormente ao dia 10 de junho de 2021, mas certamente neste mesmo ano de 2021, nesta cidade e comarca de Botucatu/SP, JOÃO MATHEUS RODRIGUES DA SILVA e o adolescente L.B.T. (fls. 10/11) associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Segundo o apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado e o adolescente se associaram para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas.

Na data dos fatos, guardas civis municipais realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, que é um conhecido ponto de tráfico de drogas e se situa nas imediações de equipamentos públicos municipais, quando avistaram JOÃO e o adolescente Leonardo.

Assim que visualizaram a viatura da Guarda Civil Municipal, o denunciado e o adolescente empreenderam fuga, razão pela qual foram perseguidos e abordados pelos guardas civis municipais.

Submetidos à revista pessoal, com JOÃO foram encontrados um rádio comunicador portátil e R\$ 90,00 em cédulas diversas, dinheiro oriundo do comércio ilícito (auto de exibição e apreensão de fls. 25/27 e comprovante de depósito de 105). Já com o adolescente Leonardo, os guardas civis municipais encontraram uma sacola contendo 96 porções de cocaína e 66 pedras de 'crack', todas individualmente embaladas e prontas para a venda, além de um aparelho celular (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 25/27, laudo de constatação provisória de fls. 29/37 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 110/112).

Indagados, JOÃO e o adolescente L. admitiram aos guardas civis municipais que realmente estavam comercializando drogas no local, o numerário encontrado era oriundo da prática da traficância e cada porção de cocaína era vendida por R\$ 20,00, enquanto cada pedra de 'crack' custava R\$ 10,00, mas não informaram quem seria o fornecedor do entorpecente (fls. 04/05). Diante destes fatos, sobreveio a prisão em flagrante do denunciado JOÃO e a apreensão do adolescente L., bem como das drogas e do dinheiro encontrado, sendo que em razão da natureza, da variedade, da relevante quantidade e da forma de acondicionamento das drogas apreendidas, assim como do conluio havido entre eles, é certo que os entorpecentes eram destinados ao tráfico ilícito.

Na delegacia de polícia o adolescente L. entregou mais R\$ 2,00 para a Autoridade Policial, dinheiro que também provinha do comércio ilícito (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 27 e comprovante de depósito de 106).

Outrossim, as mesmas circunstâncias demonstram que o denunciado e o adolescente mantinham ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo estável e permanente, voltado para a prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 (denúncia fls. 121/124).

O réu foi notificado (fls. 144), e apresentou defesa preliminar (fls. 148/152).

Durante a instrução foram ouvidas três testemunhas de acusação, duas testemunhas de

defesa, e o réu foi interrogado (fls. 240/242).

Em alegações finais orais, o representante do Ministério Público requereu a parcial procedência da ação penal, com a condenação do acusado como incurso no artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, e a absolvição do acusado referente ao artigo 35, "caput", da Lei 11.343/06.

A defesa, por sua vez, em memoriais escritos, preliminarmente requereu a rejeição de plano da denúncia, ao argumento de que não existiu conduta de tráfico por parte do réu; arguiu a ilegalidade da prisão por guardas municipais, pleiteando a rejeição da denúncia pela ausência de justa causa para a persecução penal; no mérito pleiteou a absolvição quanto ao delito do artigo 35, "caput", c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06; bem como requereu que, em caso de condenação, a pena seja fixada no mínimo legal e em regime inicial diverso do fechado (fls. 255/267).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de condutas que, em tese, estariam a configurar os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com causa de aumento de pena.

Primeiramente cabe analisar a matéria arguida em preliminar pela defesa. Verifico que o pleito de rejeição de plano da denúncia, ao argumento de que não existiu conduta de tráfico por parte do réu é matéria afeta ao mérito da ação, e nele será analisada.

No que tange à alegação de ilegalidade da prisão por guardas municipais, não merece prosperar.

Na verdade, se o Código de Processo Penal, em seu artigo 301, permite a qualquer pessoa do povo prender quem esteja em flagrante delito, não se vislumbram motivos para não o permitir aos Guardas Civis Municipais.

Nesse sentido, aliás, é o atual entendimento do E. STJ:

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. CUSTÓDIA PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (STJ, HC 402793 / SP, HABEAS CORPUS, 2017/0135683-3, 5ª Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 19/10/2017)

Note-se que não se trata de investigação entabulada pelos Guardas Civis Municipais para descobrir o autor de um crime, esta sim, considerada recentemente como ilegal pelo E. STJ, mas de uma prisão em flagrante do acusado que praticava o crime.

Assim, verifico a legitimidade da prisão, e afasto a preliminar arguida.

Na matéria de fundo, ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos crimes descritos na denúncia restaram parcialmente comprovadas.

Nesse sentido temos: o auto de prisão em flagrante (fls. 01/20); o auto de exibição e apreensão (fls. 25/27); o laudo de constatação (fls. 29/37); o laudo de exame

químico toxicológico (fls. 110/112); o laudo pericial (fls. 127/132); o relatório (fls. 114/116); os depoimentos das testemunhas, e a versão do acusado.

Interrogado em juízo o réu afirmou que não vende drogas, trabalha desde criança, e desconhece esse depoimento dos policiais. Relatou que fumava maconha, mas faz sete meses que não usa mais. Nunca respondeu a nenhum processo. Não conhecia os guardas municipais. Estava trabalhando em tapeçaria há quatro anos, tirou carta e comprou seu carro com o fruto de seu trabalho. A droga apreendida era do Leonardo. Foi preso dentro de sua casa, nos predinhos, bloco 4, apto 31-A. Conhecia o Leonardo da quadra de futebol. Na data dos fatos tinha acabado de sair da casa da Regiana, e foi enrolar um baseado para fumar, tomar um banho e ficar tranquilo, mas quando viu os policiais já estavam dentro de sua casa. Todos os moradores deixam a porta aberta (essência do depoimento de fls. 243/244).

A testemunha Carlos Alexandre Lauriano relatou que estavam em patrulhamento preventiva comunitário pelos bairros quando avistaram dois indivíduos próximos da calçada, que ao verem a viatura empreenderam fuga para os predinhos. Os acompanharam e abordaram próximo da escada que dá acesso ao bloco rosa. Com o menor foi localizada uma sacola contendo 96 papérolas de cocaína e 66 pedras de crack, e um celular. Com o réu foi localizado um rádio comunicador e R\$ 90,00 em notas diversas. Eles confessaram que realizavam a venda de entorpecentes. Não conhecia o réu e o adolescente dos meios policiais. Não entraram no apartamento do acusado. Não se recorda de ter subido ao apartamento do réu para avisar a família, somente fizeram contato no bairro vizinho, na residência do menor, para avisar seu responsável (essência do depoimento de fls. 243/244).

A testemunha L.B.T., adolescente, informou que estava no bloco 4 do CDHU, conhecido como predinhos, com droga e rádio. Chegou a Guarda Municipal, subiu correndo e acabou entrando na casa do João, e acabaram sendo presos. Afirma que o réu não tinha nada com o caso, as drogas e o rádio pertenciam ao depoente. Estava na rua com a droga, fugiu dos guardas subindo as escadas, e viu a porta aberta do apartamento do réu e entrou. Disse aos guardas que tinha corrido mas não tinha nada consigo. De imediato não assumiu as drogas (essência do depoimento de fls. 243/244).

A testemunha Victor Zambonato Bariquelli relatou que a equipe efetuava patrulhamento de rotina na região da Vila Jardim, e próximo aos predinhos da CDHU viram dois rapazes, sendo que um deles tinha uma sacola na mão. Ao notarem a viatura tentaram empreender fuga em direção aos blocos. Fizeram acompanhamento e os abordaram. Com João havia um rádio comunicador e R\$ 90,00 em notas variadas. Com o menor na sacola estavam 66 porções de crack e 96 porções de cocaína. Indagados, informaram que realizavam o tráfico no local, e os valores eram provenientes das vendas. Não conhecia os autuados. Foram abordados próximo da escada de acesso aos conjuntos de apartamentos. O familiar do adolescente compareceu ao plantão policial. Não entraram no apartamento do réu (essência do depoimento de fls. 243/244).

A testemunha de defesa Regiana Camargo Rosa relatou que é amiga do acusado, e viu o dia em que ele foi preso. Um pouco antes ele estava em sua casa, mora no apartamento ao lado. Ele foi para a casa dele e a porta de seu apartamento permaneceu aberta. Viu que subiram dois policiais, colocaram a mão na maçaneta da porta da casa dele e entraram e ele estava no interior do apartamento. Não sabe dizer se o réu tem envolvimento com drogas. O réu trabalha o dia todo, faz quatro anos nesse emprego. No prédio costumam deixar a porta destrancada, não trancam com a chave. A prisão foi dentro do apartamento do réu, ele tinha acabado de sair do apartamento da depoente. Não sabe dizer quantas pessoas estavam no apartamento do réu, mas quando estava em sua casa, o réu estava sozinho. O outro menino L. saiu preso de dentro do apartamento. Não sabe dizer como o L. entrou no apartamento do réu. É rotineira a entrada da polícia nos apartamentos (essência do depoimento de

fls. 243/244).

A testemunha de defesa Rosa Regina Rodrigues relatou que é genitora do acusado, não chegou a ver ele ser preso. Morava com ele, e nesse dia tinha saído. Ficou sabendo que o réu estava chegando com seu amigo, e estavam só os dois. Subiram para o apartamento, e ambos não tinham nada na mão. Mas antes de entrar no apartamento, o réu foi no apartamento da Regiana. Após, entrou em seu apartamento, e uns 15 minutos depois a polícia chegou atrás e prendeu os dois dentro do apartamento, dizendo que eles estavam com drogas. O réu estava só fumando um baseado, que fumava. O filho trabalhava, já há 4 anos no Severino Tapeçaria. Ele entrava às 8 e saía às 18, todos os dias, às vezes saía às 19 horas, quando havia encomenda. Eles foram presos dentro do apartamento da depoente e do réu. É costume dos moradores deixarem as portas dos apartamentos sem trancar. A polícia somente abriu a porta, sem bater nem nada. Quem relatou para a depoente foi a Regiana. Ela é uma pessoa bem confiável, que ajuda muito os meninos dali. É uma amiga muito próxima, o apartamento dela é ao lado. Tem costume de se reunir com ela, sempre estava na casa dela quando morava ali. Ela é amiga íntima da família (essência do depoimento de fls. 243/244).

Ora, apesar do acusado ter negado o tráfico de drogas, trazendo em seu interrogatório judicial uma elaborada e fantasiosa versão, o conjunto probatório demonstra o contrário.

Os guardas civis municipais prestaram depoimentos firmes e harmônicos que se coadunam com as demais provas produzidas nos autos.

A quantidade de droga apreendida, sua forma de acondicionamento, e o numerário apreendido com o acusado, tudo comprova a atividade de tráfico que era desenvolvida pelo acusado naquele local.

O acusado, por sua vez, não trouxe nenhuma prova a confirmar as suas alegações.

Anoto que os depoimentos das testemunhas de defesa devem ser analisados com reservas, por se tratar de amiga íntima da família, e da genitora do acusado, sendo que esta última foi quem revelou o grau de amizade havido com a primeira.

Além disso, o laudo de fls. 110/112 resultou positivo para cocaína e crack.

O Juiz de Direito, analisando a questão no contexto, observada a livre convicção motivada, deve decidir segundo sua consciência, buscando o alcance das verdadeiras finalidades das Leis.

Nesse diapasão:

“PERANTE O NOVO DIREITO BRASILEIRO, O JUIZ CRIMINAL É CHAMADO A EXERCER O SEU NOBRE OFÍCIO COM A SUA PRÓPRIA CONSCIÊNCIA, COM SEU PRÓPRIO RACIOCÍNIO, COM SUA LIVRE CRÍTICA. JÁ NÃO SERÁ UM INTÉRPRETE ESCOLÁSTICO DA LEI, UM APLICADOR DE JUSTIÇA TARIFADA, UM ÓRGÃO AUTOMÁTICO DE FÓRMULAS SACRAMENTAIS, MAS UMA CONSCIÊNCIA LEVRE A REGULAR DESTINOS HUMANOS” (TACRIM-SP - Rel. VALENTIN SILVA - RT 501/307).

Os depoimentos dos guardas civis municipais são coerentes. A quantidade de droga apreendida; a forma do seu acondicionamento; o numerário, e a fantasiosa versão apresentada pelo réu são suficientes para definir a finalidade de tráfico.

Como é sabido, o delito de tráfico de drogas não exige, para a sua configuração, a venda propriamente dita do entorpecente.

Nesse sentido, confira-se:

"O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663).

Ainda:

"Não é dispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido". (RT 729/542).

Diante da possibilidade da livre convicção motivada, lembremos que em se tratando de delitos clandestinos, a força dos indícios não pode ser desprezada. A respeito, vale anotar:

"PROVA INDICIÁRIA - FORÇA PROBANTE - NO QUE INTERESSA AO DIREITO PROCESSUAL, A FORÇA PROBANTE DOS INDÍCIOS É IGUAL À DE QUALQUER OUTRO MEIO DE PROVA - SE O ESPÍRITO HUMANO, NA MAIORIA DAS VEZES, NÃO ATINGE A VERDADE SENÃO POR ARGUMENTOS PROBATÓRIOS INDIRETOS, PARA EVIDENCIAR A CIRCUNSTÂNCIA IGNORADA COM O NEXO DE CAUSALIDADE, OU DE IDENTIDADE ESPECÍFICA, NÃO PODERIA, POIS, SER DESPREZADA, NOS JUÍZOS CRIMINAIS, A PROVA INDICIÁRIA, DÊS QUE CADA VEZ MAIS A INTELIGÊNCIA, A PRUDÊNCIA E A CAUTELA DOS CRIMINOSOS DIFICULTAM A PROVA DIRETA" (RT 728/478).

A coerência dos depoimentos e o bom trabalho feito pelos guardas civis devem ser prestigiados, compreendendo-se sobre a dificuldade cada vez maior na luta diária contra o crime, mormente contra o tráfico de drogas que está acabando com a nossa juventude e com suas famílias.

Além disso, ficou demonstrado o envolvimento do adolescente no delito, o qual portava os entorpecentes.

Fica bem tipificada a conduta prevista no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei de Tóxicos.

Conjunto probatório fortíssimo, não fica margem alguma para a desclassificação do tipo penal para a figura do artigo 28 da nova lei.

Não fica nenhuma dúvida para o julgador quanto à materialidade do delito e a destinação de tráfico daquelas drogas. Pontuo ainda que o tipo penal é de ação múltipla e conteúdo variado, estando bem tipificada a conduta pelo fato do réu e do adolescente trazerem consigo drogas, para aqueles fins.

Por fim, diversamente do sustentado na exordial, entendo que não está configurada a associação criminosa, nos moldes do artigo 35 da Lei de Tóxicos.

A jurisprudência já se posicionou no sentido de que para configuração do delito, mister que haja prova da efetiva associação para a traficância em outros negócios, não bastando que seja ocasional.

Nesse sentido, aliás, já se pronunciou o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"TÓXICO - Tráfico - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Concurso de pessoas - Prova cabal apenas de reunião dos denunciados para a traficância - Não se ficou sabendo, ao certo, de quantos negócios similares participaram os réus, um deles já falecido - Não caracterização do delito autônomo de associação previsto no artigo 14 da Lei 6.368/76, que não pode confundir-se com simples co-autoria - Aumento da pena prevista no artigo 18, inciso III, da referida lei, em grau máximo, em razão da periculosidade do apelado - Recurso provido." (Apelação Criminal n. 235.327-3 - Guaratingueta - 6ª Câmara Criminal - Relator: Debatin Cardoso -

24.09.98 - V.U.)

“REVISÃO CRIMINAL - Entorpecente - Tráfico - Concurso de pessoas - Reunião do peticionário com outras pessoas para a traficância apenas ocasional - Participação que se limitou a um único negócio - Não caracterização - de delito autônomo de associação e formação de quadrilha, prevista no artigo 14 da Lei 6.368/76, que não pode confundir-se com simples co-autoria - Aumento de pena, pela incidência do artigo 18, inciso III da Lei 6.368/76 - Revisão parcialmente acolhida.” (Revisão Criminal n. 227.286-3 - São Paulo - 3º Grupo de Câmaras Criminais - Relator: Debatin Cardoso - 10.09.98 - M.V.)

“ENTORPECENTE - Tráfico e Associação - Artigo 12 caput e 14 da Lei 6.368/76 - Descaracterização da associação prevista no artigo 14, por não comprovada a habitualidade - Reclassificação para o delito do artigo 18, inciso III, da referida Lei - Recursos parcialmente providos.” (Apelação Criminal n. 230.120-3 - São Paulo - 3ª Câmara Criminal - Relator: Oliveira Ribeiro - 03.03.98 - V.U.)

Anoto que, embora haja indícios de que a associação seja habitual, tal matéria não restou incontestada nos autos, até porque não foi produzida nenhuma prova como campana policial, interceptação telefônica e delação que pudesse demonstrar a habitualidade do acusado e do menor na prática da mercancia, e a estrutura e organização da associação.

Nesse diapasão, não havendo elementos seguros a indicar a associação para o tráfico, inviável a condenação nessa parte, aplicando-se o “in dubio pro reo”.

Assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local descrito na denúncia, o acusado juntamente com o adolescente trazia consigo drogas, para fim de tráfico ilícito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, “caput”, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº. 11.343/06.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

Considerando os ditames do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06, levando-se em conta a grande quantidade e potencialidade dos entorpecentes (96 porções de cocaína e 66 porções de crack), quantidade essa suficiente para grande disseminação na sociedade, tudo a atingir a juventude, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal. Não se vislumbram atenuantes ou agravantes.

Por força da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, tendo em vista que o delito envolveu adolescente, majoro a pena de 1/6, perfazendo-se 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

O réu não faz jus ao disposto no artigo 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06, pois a grande quantidade de entorpecente demonstra o grau de envolvimento com o tráfico e que não se trata de “marinheiro de primeira viagem”. Assim, o réu não pode ser tratado igual aos traficantes neófitos, que tem ao seu favor a causa de diminuição de pena acima mencionada. Entender de forma contrária seria no mínimo ferir o princípio da isonomia, e dar um tratamento benéfico àqueles que traficam em larga escala, algo não pretendido pela Lei 11.343/06.

Nos termos do referido dispositivo legal, entendo que o magistrado poderá reduzir a

pena fixada ao agente - de um sexto a dois terços - desde que este seja primário, não possua antecedentes criminais, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Cuida-se, pois, de faculdade que o Juiz de Direito usará ou não, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, e não direito subjetivo do acusado. Na aplicação do preceito o Juiz deve verificar, também, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime, sem o que estará ferindo o princípio da individualização da pena. E, na hipótese vertente, repito, tendo em vista as circunstâncias que envolveram a prisão dos réus, não há dúvidas de que se dedicavam ao comércio ilícito de entorpecente e, portanto, ostentam periculosidade maior. Assim, inviável a diminuição de pena supramencionada.

Nesse diapasão, cumpre trazer à baila recente acórdão prolatado pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, em autos sentenciados por este magistrado, assim ementado:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. PENA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA, ANTE A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, EM RAZÃO DA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231, DO STJ. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

1. A remissão feita pelo Magistrado referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Precedentes do STF (AI 825.520 AgR-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 31.05.2011; AI 814.640/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02.12.2010; HC 92.020/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 21.09.2010; HC 101.911/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27.04.2010; HC 100.221/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04.05.2010; HC 94.384/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 02.03.2010; Emb. Decl. MS 25.936-1/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13.06.2007; HC 98.814/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 23.06.2009; HC 94.243/SP, Rel. Min. Eros Grau, j. 31.03.2009; HC 96.517/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03.02.2009; RE 360.037/SC, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 07.08.2007; HC 75.385/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, j. 07.10.1997).

2. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas. Substância entorpecente encontrada na posse do réu.

3. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 1ª Câmara Criminal Extraordinária Voto n. 3.999 - Apelação n. 0006177-49.2014.8.26.0079 3 civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC 73.518-5 Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco

Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10).

Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.05.14; RHC 45.173/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 26.05.14; HC 109.105/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 23.02.10).

4. Pena mantida conforme fixada na Origem.

5. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal ante o reconhecimento de circunstâncias atenuantes. Entendimento da Súmula n. 231, do STJ.

6. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os petrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primacialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STF.

7. Regime inicial de cumprimento de pena para o crime de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, órgão constitucionalmente competente para tanto.

8. Improvimento do recurso defensivo.(TJ/SP, Apelação Criminal n. 0006177-49.2014.8.26.0079, 1ª Câmara Criminal Extradordinária, Des. Relator Airton Vieira, julgado em 03 de fevereiro de 2016, grifei).

A pena restritiva de liberdade será cumprida em regime inicialmente fechado, consoante art. 2º., §1º., da Lei nº. 8.072/90, na redação dada pela Lei nº. 11.464/2007.

Nego o direito ao réu de apelar em liberdade, porque se trata de crime que coloca em risco a população desta cidade. Trata-se de crime equiparado a hediondo, que movimenta toda uma estrutura criminosa, não bastasse a reincidência do réu.

Torno definitiva a pena em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor menor.

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR JOÃO MATHEUS RODRIGUES DA SILVA ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor menor; por infração ao artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06; e, em prosseguimento, para ABSOLVÊ-LO com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da imputação da prática do crime previsto no artigo 35, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Decreto o perdimento do numerário e bens apreendidos (fls. 25/26), na forma do artigo 63 da Lei nº. 11.343/06, pois vinculados à prática do comércio ilícito, não havendo nos autos qualquer prova em contrário. Expeça-se o necessário, oportunamente.

Caso algum dos bens apreendidos não possuam qualquer valor comercial, deixo de decretar o seu perdimento e autorizo a sua destruição, nos termos dos artigos 25 a 28, da Portaria SENAD nº 01, de 10/01/2020. Expeça-se o necessário, oportunamente.

O réu, se insatisfeito com a decisão, não poderá recorrer em liberdade. Recomende-se o réu na unidade prisional em que se encontra.

Em que pese o disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.736/12, deixo de aplicar a detração no presente caso porque o sentenciado, por ser primário, não cumpriu 2/5 da pena, nos termos do artigo 2º, §2º, da Lei nº 8.072/90. A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, conforme determinado pela nova lei, é apenas para fins de regime de pena, ou seja, em relação apenas ao início de cumprimento da pena, de modo que se este não for alterado, não pode haver cálculos para diminuir a reprimenda, sob pena de se interferir na competência do Juízo da Execução Penal. Assim, no presente caso, o regime de cumprimento de pena não será alterado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado.

Anoto a recente decisão prolatada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar recurso de sentença proferida por este magistrado:

"Incêndio qualificado - Confissão judicial - intenção de causar incêndio bem comprovada - Fogo em casa habitada, com exposição dos vizinhos e demais moradias a perigo - Palavras da vítima e policiais - Responsabilidade comprovada - Dolo caracterizado - Condenação mantida; Incêndio qualificado - Progressão de regime - Aplicação do art. 387, §2º do Código de Processo Penal - Benefício exige o cumprimento de condições objetivas e subjetivas - Questão a ser aferida pelo juízo das execuções - Exegese do art. 66, inciso III, "c", da Lei nº 7.210/84 - Recurso improvido". (Apelação criminal n. 3004354-23.2013, 4ª Câmara de Direito Criminal, Des. Relator Alexandre Almeida, julgado em 27 de abril de 2016).

Expeça-se certidão de honorários ao defensor dativo, conforme Convênio Defensoria/OAB, se o caso.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Por fim, nos termos do Provimento CSM nº 2482/2018 (DJE 24/10/2018, p. 02/03) e artigo 525 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça, defiro a incineração das amostras guardadas para contraprova. Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

Botucatu, 31 de março de 2022.

Josias Martins de Almeida Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA